

制度必然還是歷史偶然？ —— 從十個觀點評析司法院建構的裁判憲法審查制度

蘇永欽*

目次

前言	陸、和諧互動觀點
壹、憲法解釋觀點	柒、機關產能觀點
貳、保護漏洞觀點	捌、民主轉型觀點
參、社會脈動觀點	玖、路徑依賴觀點
肆、核心權限觀點	拾、立法技術觀點
伍、功能妥適觀點	結語

〔責任校對：黃品瑜〕。

* 國立政治大學講座教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/31418002.pdf>。



前 言

司法院於2018年3月提到立法院的司法院大法官審理案件法修正草案(草案將法律更名為「憲法訴訟法」),已於同年12月通過,並於翌年1月4日經總統公布,將在三年後開始施行。新法第59條是這樣規定的:「人民就其依法定程序用盡審級救濟之案件,對於受不利確定終局裁判所適用之法規範或該裁判,認有抵觸憲法者,得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。前項聲請,應於不利確定終局裁判送達後六個月之不變期間內為之。」繼於第61條規定:「本節案件於具憲法重要性,或為貫徹聲請人基本權利所必要者,受理之。審查庭就承辦大法官分受之聲請案件,得以一致決為不受理之裁定,並應附理由;不能達成一致決之不受理者,由憲法法庭評決受理與否。前項一致決裁定作成後十五日內,有大法官三人以上認應受理者,由憲法法庭評決受理與否;未達三人者,審查庭應速將裁定公告並送達聲請人。」第62條規定:「憲法法庭認人民之聲請有理由者,應於判決主文宣告該確定終局裁判違憲,並廢棄之,發回管轄法院;如認該確定終局裁判所適用之法規範違憲,並為法規範違憲之宣告。第五十一條及第五十二條規定,於前項判決準用之。」

此處修改重點在以確定終局裁判本身的合憲性為判決標的,也就是修正草案總說明所稱的「裁判憲法審查」,依該說明建立此制的目的就在:「使大法官憲法審查效力擴及於法院確定終局裁判,提供人民完整而無闕漏之基本權保障。」在前引各條的立法理由中也多次提到參考德國聯邦憲法法院法的憲法訴願(Verfassungsbeschwerde)程序保障人民基本權的意旨,比如第59條的立法說明即為:「1、按憲法是國家的根本大法,具有保障人民基本權利功能的最高效力,所有國家權的行使,皆不應違背憲法的規定,更應致力於保障人民在憲法上的基本權利。當國家權力的行使(例如法

律、命令）有違反憲法的疑慮時，審查相關制度就應該裁決這些國家權力行使是否合憲，守護人民的基本權利，免於國家權力的恣意侵害。而這些可能侵害人民憲法上權利的國家權力，不僅包括立法權與行政權，也包括司法權。2、在現行條文第5條第1項第2款既有之確定終局裁判適用之法規範審查制度下，大法官只進行抽象規範審查，不具體裁判憲法爭議，僅能抽象闡述法律的內涵為何、是不是符合憲法的意旨，而不能將這些闡述直接應用在個案中的具體事實。亦即，現行大法官職司的憲法審查並無處理各法院裁判在解釋法律及適用時，誤認或忽略了基本權利重要意義，或是違反了通常情況下所理解的憲法價值等司法權行使有違憲疑慮的情形。3、配合本法引進『裁判憲法審查』制度，於本項併將現行條文第5條第1項2款之法規範及該確定終局裁判二者，納入人民得聲請憲法審查之客體，俱屬憲法法庭所得審理之案件類型。……」第61條的立法說明中並稱「擷取德國聯邦憲法法院施行裁判憲法審查制度之經驗」，顯然即以裁判憲法訴願與裁判憲法審查為同義詞，有關德國的憲法訴願程序在我國的研究已多，其標的涵蓋所有公權力，至於所謂的裁判憲法訴願（Urteilsverfassungsbeschwerde），本就包含以裁判本身違憲，及裁判所適用的法規範違憲兩種次類型，後者因仍以裁判為侵害基本權的公權力，而非裁判所適用的法規範，因此又稱為間接法規範憲法訴願（mittelbare Rechtssatzverfassungsbeschwerde），而與直接以法規範侵害基本權（並未通過處分或裁判）的法規範憲法訴願性質不同，後者新法並未納入。因此第59條的設計，實際上是在加入單純裁判審查以外，把原有的由人民聲請所為的規範審查也變成了裁判憲法訴願的一種類型，使該原因案件也一併納入大法官的審判範圍¹，容後再論。

¹ 從新法第62條對兩種情形都直接廢棄該確定裁判即知，這就是把原來屬於Georg Brunner所描述的，以法規範審查為真正標的，僅附帶提供個案再審救濟的非真正基本權訴願（unechte Grundrechtsbeschwerde），改為包括裁判本身和「因」法規範而使裁判違憲的真正基本權訴願。可參見Georg Brunner, Der

對於這種由憲法法院來審查終審法院判決的制度，我過去零零星星已經談了很多，此處為追思我輩無不尊崇景仰的前大法官，同時也是中華民國憲法學會前理事長的吳庚老師，我想就以司法院已經具體提出的條文為對象，對這個可能大幅改變我國大法官解釋制度、乃至顛覆司法權內部分工的立法構想作更全面的討論，期能引起法政學者的重視，在變制之前也一起深入思考，為我國的釋憲制度改革找到正確的方向。個人整理了十個不同的觀點廣泛省思之後，整體的結論還是：實在找不到足以支持此一建制的理由。

壹、憲法解釋觀點

大法官可不可以審查個案決定，包括行政和司法決定，憲法其實是有解釋空間的，憲法第114條和第171條賦予大法官的違憲審查權雖然都以法規範為標的，但第78條和第173條賦予大法官的是概括的解釋憲法權，不像德國基本法那樣對聯邦憲法法院的職權不僅採憲法保留，且以列舉規定為原則（Enumerationsgrundsatz），因此有關大法官職權行使的法律如果要把違憲審查的標的延伸到行政或司法的個案決定，好像並無不可。

但大法官自己在司法院釋字第527號解釋和司法院釋字第553號解釋都相當明確的做了大法官依憲法只能對抽象法規範作違憲審查的論述，在司法院釋字第527號解釋的理由書是這樣說的，「衡諸憲法設立釋憲制度之本旨，係授予釋憲機關從事規範審查權限（參照憲法第78條），除由大法官組成之憲法法庭審理政黨違憲解散事項外（參照憲法增修條文第5條），尚不及於具體處分行為違憲或違法之審查。」司法院釋字第553號解釋就講得更清楚了，而且直接寫

Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Raum, JöR 50 (2002), S. 191-255.

在解釋文中：「憲法設立釋憲制度之本旨，係授予釋憲機關從事規範審查（參照憲法第78條），除由大法官組成之憲法法庭審理政黨違憲解散事項外（參照憲法增修條文第5條第4項），尚不及於具體處分行為違憲或違法之審理。本件行政院撤銷台北市政府延期辦理里長選舉之決定，涉及中央法規適用在地方自治事項時具體個案之事實認定、法律解釋，屬於有法效性之意思表示，係行政處分，台北市政府有所不服，乃屬與中央監督機關間公法上之爭議，惟既屬行政處分是否違法之審理問題，為確保地方自治團體之自治功能，該爭議之解決，自應循行政爭訟程序處理。」兩號解釋雖都沒有明文排除確定終局裁判，但從規範審查不涵蓋具體處分行為的審查，邏輯上已經很難為大法官就同樣是具體公法行為的裁判擠出違憲審查的空間了。司法院釋字第553號解釋共有陳計男大法官、孫森焱大法官、戴東雄大法官和蘇俊雄大法官提出協同意見書，曾華松大法官提出部分不同意見書，劉鐵錚大法官和謝在全大法官提出不同意見書，不論理由不同或結論不同，七位大法官都沒有就大法官不得對具體處分行為進行憲法審查一點表達任何異議，其中劉鐵錚大法官雖認為大法官應對臺北市政府的處分是否合法依地方制度法的授權做出決定，仍非憲法審查，謝在全大法官則剛好相反，不僅認為合法性的判斷應保留給普通法院，有關法律的解釋也不宜越俎代庖，大法官只能做抽象的規範審查，足見對於大法官解釋權的範圍不及於個案決定實有高度共識。兩解釋之後才修改的憲法增修條文第5條第4項，在政黨違憲解散之外增列總統、副總統的彈劾為大法官組成憲法法庭審理事項，也以行動回應了大法官在兩件解釋實質上建立的「憲法法庭個案審理權採憲法列舉原則」。

值得注意的是，在這兩件解釋大法官都不是僅從解釋程序法上論述大法官有無對具體決定作憲法審查的權限，而是直接根據憲法第78條的規定，認定大法官的解釋權應以對抽象規範做憲法審查為其極限。其中司法院釋字第527號解釋雖只見於理由書，但其論述

即為支撐解釋文的主要理由（tragende Gründe），應可無疑。司法院釋字第553號解釋更是直接寫在解釋文，其對所有機關與人民的拘束力（司法院釋字第185號解釋參照），更無待贅言。大法官雖不受過去解釋的絕對羈束，但行使法案提出權的司法院只是司法行政權的主體，不是行使解釋權的大法官，此一定性即使在民國92年改制，院長副院長都由大法官並任後也無不同，至於審議法案的立法院，更無不受解釋拘束之理。因此在大法官明確變更此一見解以前，直接修法使大法官得對具體個案的確定終局裁判做憲法審查，是否合憲，問題恐怕不小。

但即使撇開大法官解釋直接排除立法空間這一點，從憲法法院和既有法院體系間如何分權去思考，仍有許多重要觀點值得一併探討，設置了憲法法院的國家也已經有豐富的經驗可以借鏡²，以下即從較不熟悉大陸法系國家憲法法院制度者經常提起的基本權保護漏洞和抽象審查難以掌握真實社會脈動這兩個論點接續討論。

貳、保護漏洞觀點

Mauro Cappelletti針對違憲審查的制度首先提出的集中、分散二分法，有時會讓初學者誤以為分散既指由所有法官共同承擔，則集中應指由特定法官專司憲法審查，其他法官無從分享或分擔此部分的審判權，就像民事刑事行政事件審判權的劃分一樣。然而憲法在20世紀的發展，特別是有關人民基本權的部分，早已不限於對最

2 這是所有設置憲法法院國家的宿命和必須通過的考驗，可參見Lech Garlicki, *Constitutional Courts versus Supreme Courts*, 5 INT'L J. CONST. L. 44, 44-68 (2007); Conference of European Constitutional Courts XIIth Congress, The Relations between the Constitutional Courts and the Other National Courts, including the Interference in This Area of the Action of the European Courts, Brussels (May 14-16, 2002)各篇報告。

高公權力的制約，而有以其整體建構的價值秩序引領各法域規範內涵的解釋、乃至形成的作用，隨著憲法由上而下的浸潤各法域，所有法官在適用法律的時候都越來越頻繁的引用憲法。而且除了朝合憲方向為法律解釋外，法官對位階低於法律的抽象規範，基於法制內部無矛盾的考量（和美國1803年最高法院在*Marbury v. Madison*一案的推理沒有兩樣），有時還要承擔一部份規範違憲審查的工作，這也使得特設的憲法法院，對憲法事件的管轄權不可能像民事法院或行政法院那樣就私法和公法事件做相互排除的概括規定，因為公私法事件都可能因涉及上位階的憲法問題而同時具有廣義憲法事件的性質，因此特設憲法法院的管轄必然是「選擇性」的憲法事件，若非普通法院管轄權所不及——憲法保留或事物本質的保留（無可訴性）——，即為與普通法院有競合的審查權，比如在我國憲法第172條未如第171條就法律違憲的認定為大法官做保留，則大法官固可依其一般的解釋權審查並認定行政命令違憲，一般法官依憲法第80條的規定也有審查命令有無違憲並為認定的權力，其不同僅在於程序的設計，即憲法法院通常就以命令違憲與否為本案事件而做成決定，非如一般法院僅以其為本案爭議需要先行判斷的先決問題，而附帶於民事或行政事件做成是否得適用該命令的決定³。上級法院在審查下級法院裁判合法性時，也必然要從憲法觀點檢視，其程序進行或實體論證有無憲法上的瑕疵而為維持、廢棄的判斷，從而當然具有廣義憲法法院的實質，這一點，我國大法官早在行憲之初就曾在司法院釋字第9號解釋第1段做了清楚的闡明：「裁判如有違憲情形，在訴訟程序進行中，當事人自得於理由內指摘之。」因此在管轄上所有憲法法院都只能採列舉原則，而非概括原則，各國間的差異只在於不同分權考量而有不同的職權分配，以及其列舉為憲

3 分工的情形當然會因各國法制傳統而有出入，比如對於行政命令的審查，法國和韓國都交由一般的終審法院，奧地利則由憲法法院獨占（一般法院若有違憲確信必須停止審判聲請憲法法院認定），德國和我國則是競合行使違憲審查。

法保留（如德國、奧地利、南非）或法律保留（如我國、法國、韓國）而已，前已提及。即使在一般會交由憲法法院獨占的法律違憲審查，程序設計上往往也課與各法院的法官在承審案件中先為審查的義務，僅於形成違憲確信時，才可裁定停止訴訟程序聲請就此先決問題由憲法法院做成法律有無違憲的決定；甚至如法國，還要先送終審法院做最後過濾，才送憲法委員會⁴。足見所謂的集中審查，實際上也必以「分散」的充分分工才能運作，所有的法官都要有高度的憲法意識，並隨時參與憲法的落實，如德國聯邦憲法法院成立時發布備忘錄中所說的，對人民而言，憲法法院最好只是「可以不走的繞路」（vermeidbarer Umweg），能不自己做就盡量不自己做，又稱「補充原則」（Subsidiaritätsprinzip）。所以如果正確理解憲法法院的集中審查模式，就知道包括Hans Kelsen在內的所有制度設計者，都很清楚這是一種分進合擊的集中，因此僅從集中審查表面的字義，就想當然爾的推論在憲法法院和普通法院之間是採水平分工，一如民事、刑事、行政事件審判權之間一般，從而如果不把各種個案決定的憲法審查也納入憲法法院的審判權，就會發生基本權保護的漏洞，自然就謬以千里了⁵。

4 詳參吳秦雯，事後違憲審查之潮流？——淺析法國違憲審查制度之新變革，憲政時代，36卷4期，頁375-409（2011年）；李鐸澂，法國憲法委員會組織法、憲法委員會處理違憲先決問題內部規則、憲法委員會委員義務律令之中文翻譯，憲政時代，38卷1期，頁57-104（2012年）。

5 在司法院提出的草案第59條，原來還參考了德國聯邦憲法法院的實務，以第2項要求「聲請裁判憲法審查，以聲請人曾於審級救濟程序中主張違憲事由者，始得提起。但構成違憲之情事係確定終局裁判所致，而聲請人不及主張者，不在此限。」並於理由中為以下說明：「鑒於維護並實現憲法基本權利之保護，不僅係憲法法庭之職責，亦係各法院之重要任務，因此人民如認有違憲之事由，應在審級救濟程序中即時主張，期使由各法院盡其應盡之保障基本權利職責，而非至確定終局裁判作成，始向憲法法庭有所指摘。爰於本項規定，人民認其所受之不利確定終局裁判違憲，聲請憲法法庭為裁判憲法審查，以聲請人曾於審級救濟程序中主張者，始得提起，以彰顯憲法法庭於憲法審查制度之補充性地位，並藉以提升各法院之憲法意識。惟如構成違憲之事由發生係由確定終局裁判所致，聲請人於審級救濟程序中自無機會再予主張，爰設但書予以除外規定，以資周全。」顯示司法院也是基於相同的認知設計此制，此項在立法

人民可以在訴訟中請求法官排除行政處分或裁判對基本權造成的侵害，請求法官審查所要適用的行政命令是否違憲而不用，甚至在法律可能違憲的情形，請求法官裁定停止訴訟程序聲請大法官就有無違憲做成決定，如果法官同意違憲的判斷，只有在「法律」違憲的情形，還不能自己排除人民基本權受侵害的瑕疵，則要不要增設大法官對普通法院裁判的憲法審查權，無論如何不能以人民司法受益權的保護出現漏洞為理由，如司法院提案所主張。事實上大法官對於憲法保障的人民訴訟權，向來都以「有權利必有救濟」的第一次救濟為其核心保障範圍，像這樣第一次救濟已經存在，只有「要不要增設一級救濟」的問題，則一貫認為屬於立法裁量的範圍（司法院釋字第393、442、512、639等號解釋可參），不可能因為未增設大法官的裁判審查而違反訴訟權的保障。各級法院在審判程序和裁判中做成憲法判斷而使人民的基本權受到保障，或憲法原則浸潤法律解釋的案例已經很多，這裡僅信手拈來各舉一例說明。

臺北地方法院行政訴訟庭在處理一件因違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款規定而被開罰單的案件時，法官在判決中便寫了這樣一段話：「……於涉有人民行使其表現自由之情形，行政機關於執法時，自應更嚴格審酌……以免造成言論自由之不當限制。本件原告係以看板之文字圖片於人行道表現其意見，此也為民主國家常見之情景，然被告並未充分審酌原告於前揭時地持看板於人行道行為之各個具體情況，而尚未達足以妨礙交通，即以處罰條例第82條第1項處罰，不但已有違誤，復造成對於原告言論自由之不當限制，原處分自當予以撤銷。」（臺灣臺北地方法院104年度交字第188號行政判決）臺灣高等法院曾就民事證據能力問題在判決中對兩個基本權衝突的問題表示以下的見解：「訴訟權之保障與隱私權之保護，兩者有發生衝突可能，如因侵害隱私權而取得之證

院被刪除，原因為何並不清楚，但引進裁判憲法審查不是以原來制度上存有漏洞，最多只是「加強」憲法的保護，僅從此一規定已足可說明。

據，或以不法方式取得之證據，法院應否以欠缺證據能力，予以排除問題。在民刑事訴訟程序應以分別看待，持不同之審查標準。刑事訴訟程序，因以國家強大司法體系，由檢察官法官代表國家行使追訴審判權，國家與被告顯立於不公平位置，不法取得之證據，其證據能力應嚴格對待，以證據排除法則限制司法權之作為。但民事訴訟程序，對立之兩造立於公平地位，於法院面前為權利之主張與防禦，證據之取得與提出，並無不對等情事，較無前述因司法權之強大作用可能造成之弊端，因此證據能力之審查密度，應採較寬鬆態度，非有重大不法情事，否則不應任意以證據能力欠缺為由，為證據排除法則之援用。隱私權及訴訟權均為憲法所保障之基本權，當兩者發生衝突時，憲法之比例原則，應可做為審查標準。」（臺灣高等法院94年度上易字第243號刑事判決）終審法院則可以最高行政法院一件命令違憲審查為例：「……原處分所依據者為國軍軍紀維護實施規定第2章第13節『國軍飲酒駕車處分規定』，查該規定並未經法律明文授權訂定，應屬行政機關內部之行政規則，依司法院釋字第491號解釋意旨，自難作為對軍人記兩大過並為不適服現役決定，剝奪上訴人軍人身分之依據。退而言之，縱認該行政規則無違法律保留原則，然該規則不分任何情節輕重，僅以酒醉達一定程度一律記兩大過並經人評會審查不適服現役，為就有無肇事、有無致人損害、影響軍紀是否重大及飯後態度等情節，作不同處罰之程度或賦予執法者依情節裁量之餘地，是該規定自有違憲法第23條所定比例原則而無從適用。」（最高行政法院99年度判字第639號判決）

一般法院在審判中既應依據包括憲法在內的法律獨立審判，上級法院對於下級法院的裁判做合法性審查時，也都要作違憲性審查，制度上當然就不存在司法受益權的漏洞。至於實務上普通法院上級審對下級法院裁判的合法性審查可能偏向法律位階而較忽略憲法觀點，也不是制度本身的問題，最近司法院在推動審級制度改

革，使三審級的功能也更「金字塔化」時，更刻意把終審法院變成以合憲性審查為主，亦可說明所謂基本權保護漏洞說之無稽⁶。

參、社會脈動觀點

另外一個觀點也是源於對所謂集中式違憲審查的錯誤想像，以為只有採分散式審查時，因為都是附帶於一般案件進行，使得憲法問題才真能在社會生活中非常具象的呈現，憲法法院如果只做規範的違憲審查，抽象的比對法律和憲法的相容性，很難掌握社會真正的脈動，和人權保障不足的細節，因此即使功能上可能和審理個案的普通法院有些重疊，只有讓專司憲法審判的憲法法院也能直接審理個案決定的合憲性，才可使憲法法院的憲法思維更加細緻，而不流於空泛。

這樣的看法忽略了此問題的真正關鍵在於讓憲法法院發動審查的「原因」，而不一定把答案限制在是否以個案決定為違憲審查的「標的」。只要使人民的個別人權遭遇同樣可以促成憲法法院的規範違憲審查，思考過於抽象、空泛的質疑就可化解⁷。比較觀察各國憲法法院的實際發展，直接或間接由人民發動其實一直是主要的趨勢，奧地利剛在1920年設立憲法法院時還只有機關發動程序，沒幾年就察覺基本權的問題意識不能不從個案去發掘，從而又修憲建制了由承審法官裁定停止審判移送憲法法院的所謂具體規範審查程序

6 可參看最近司法院依「金字塔型訴訟制度改革計畫」所提刑事訴訟法的修正案，其第377條就把現行的「上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。」限縮為：「上訴於第三審法院，除有特別規定外，非有下列情形之一為理由，不得為之：一、判決牴觸憲法或所適用之法令牴觸憲法者。二、判決違背司法院解釋者。」

7 在分散審查制下，當法官必須做法律有沒有違憲的通案思考時，同樣要把具體的個案爭議放在一邊，此時個案的功能也只是讓法官更真切的感受違憲的社會效應，與集中審查制下大法官的思考沒有本質的不同。

(konkrete Normenkontrolle)。我國的大法官解釋制度在過去30年也明顯從機關發動轉向人民發動——受理和解釋件數都在90%以上，所採的程序也可歸類於Georg Brunner所稱的「非真正基本權訴願」(unechte Grundrechtsbeschwerde)類型，也就是把聲請人遭遇的個案決定當成「原因案件」(Anlassfall)，是所引發的規範違憲爭議受理與否的程序要件，儘管解釋的標的仍只限於該規範的合憲性，大法官對於原因案件本身程序或見解的合憲性不做審查⁸，但聲請人的原因案件同樣可以具體凸顯法律的憲法瑕疵衍生的社會問題。另外大法官在司法院釋字第371號解釋突破司法院大法官審理案件法(下稱大審法)第5條第2項的聲請權限制，創設一般性的具體規範審查程序，同樣以實際繫屬法院的個案為原因案件，緊緊掌握社會脈動。下表應該可以顯示，由人民和法官發動的規範審查在大多數的憲法法院實際上都已經是主流，這也才使得憲法法院的規範審查能夠貼近社會。從這個比較可以看得清楚，要讓憲法法院的違憲審查貼近社會脈動，制度上仍可有多種選擇，裁判憲法審查最多只是一個選擇，絕對不是唯一。如果同樣可以達到貼近社會脈動的目的，負責任的立法者當然應該選擇副作用最少的，而不是副作用最多最大的裁判憲法審查。

8 至於如果憲法法院審查結果認定法律確實違憲時，聲請人可以向一般法院聲請再審，而非如其他受到違憲法律之害者一樣無從救濟，則只是為表彰其對憲法的貢獻(我國大法官在司法院釋字第725號解釋的用語)，嚴格而言，並非其訴訟權當然應有的保障，此為奧地利憲法法院模式一貫的解釋，可參Heinz Schäffer, in: Kneihls/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht, 2001, Art. 140 Anm. 93.

表1 憲法法院的九種規範審查制度類型

程序類型	有此制的國家	聲請人	有無具體個案	程序性質
直接法規憲法 訴願*	德、奧、匈、 南非、韓	人民	有，法規直接 侵害基本權	主觀，請求 排除侵害
間接法規憲法 訴願*	德、匈、南非	人民	有，用盡救濟 程序	主觀，請求 排除侵害
事前抽象規範 審查	法、西、葡、 匈、波、南非	機關/ 議員/ 團體	無	客觀
事後抽象規範 審查	德、奧、義、 西、比、臺、 匈、波、南非	機關/ 議員/ 團體	無	客觀
準民眾訴訟 (事後)	比、瑞士(巴 賽爾—藍夏福 特邦、尼德瓦 登 邦)、希 臘、斯洛維尼 亞、多明尼加	人民	無	主觀/客觀
民眾訴訟 (事後)	匈(舊制)、 喬治亞、馬其 頓、列支敦斯 登、巴西、哥 倫比亞、委內 瑞拉、德國巴 伐利亞邦	人民	無	客觀
先決問題規範 審查	德、奧、義、 西、比、臺、 韓、匈、波、 南非	法官	有，案件繫屬 法院	客觀
先決問題規範 審查	法、韓、奧、 臺(前草案)	人民	有，案件繫屬 法院	客觀

程序類型	有此制的國家	聲請人	有無具體個案	程序性質
非真正憲法訴願	奧、俄、波、匈、印尼、臺	人民	有，用盡救濟途徑	客觀，但有誘因性質的救濟

資料來源：作者編製，內容主要參考Georg Brunner, Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Raum, JöR 50, S. 191-256。

* 其中只有憲法訴願保有主觀性質（先決的規範審查仍屬客觀性質），其餘的規範審查都是沒有當事人的客觀程序，任何嗣後的救濟都只是制度設計的誘因，非本案程序的標的。

肆、核心權限觀點

我們還可以再從國家分權的兩個重要觀點來探討：核心權限和功能最適，看看裁判憲法審查是不是憲法法院不可少的東西，沒有它就不是完整的憲法法院。以及反過來，只有憲法法院最能適任這個工作，其他法院都不如它。

就先說核心權限吧。這裡要問的是，根據憲法文本，或者類似政府、國會那樣源於歷史的、系譜學上的功能，可否肯定的說，裁判憲法審查屬於憲法法院的核心功能，沒有它就不成其為憲法法院？就我國而言，大法官的職能憲法上只有簡單的規定，但從憲法第171條看來，法律的違憲審查可認定為核心職能無疑，主要憲法機關之間的分權爭議是否應由大法官扮演主要的仲裁者，即未見規定，不過有關中央與地方的垂直分權，又見於憲法第114、115、117條，民主化後制定的增修條文再增加了政黨解散和總統副總統彈劾案的審判，只有裁判憲法審查在憲法上顯然找不到任何依據，如果一定要說它是大法官基於憲法的核心功能，只能再通過比較和歷史的研究，看看能不能解釋出類似國會調查權的「固有權能」或司法保全的「核心機能」地位（司法院釋字第585號解釋）。

然而從憲法法院制度的淵源來看，Kelsen從來不認為憲法法院應該去管到個案裁判⁹，事實上不論德、奧，對於規範審查才是憲法法院的核心功能，幾無異見¹⁰。為什麼同樣作合憲性審查，法律的審查是憲法法院的核心功能，法院裁判的審查就不是，這裡顯然觸及了憲法「司法化」的兩個截然不同的面向，我一向用憲政司法（constitutional justice）和憲法司法（constitutionalized justice）來區隔。簡言之，如果我們正確理解現代憲法的雙重規範性，也就是前面提到的，一方面它要規範統治者的組織和行為，確保不致濫權，這是憲法最傳統的功能，另一方面，憲法內含的基本價值決定，也要適時投射入一般法律制度的運作而使國人共營的社會生活不致乖離這些價值決定，這部分功能則是到了20世紀才被發現和體現，有稱之為憲法的法律化，也有反過來看成法律的憲法化的，至於制度化的操作，在習慣了多元審判體系的大陸法系國家很自然就把前一制衡統治者的功能集中交給特設的憲法法院，而由既有的審判權主體分散行使後一把憲法融入法律的功能。用德國國家學的概念來理解，前者是以妥適處理憲法與民主政治間隱含的緊張關係為目的，後者則以貫徹憲法價值於整體法律秩序為目的，前者調和國家的政治意志（Machtwille）與法律意志（Rechtswille），後者根本無涉政治意志，審查對象非政治決定而為單純的司法決定或其他個案決

9 Kelsen早在1928年國家法學者年會一篇膾炙人口的演講：「國家法院的本質與發展」中就明確指出，要劃分清楚憲法法院和行政法院的審判權可說困難重重，此一兩難的擺脫只有一途，就是不要把所有直接間接和憲法有關的行為都放在憲法法院的審查權下，僅間接相關的個別行為（Einzelakt），應該由行政法院管轄，只把非它不可的重大憲法問題交給憲法法院，可參Hans Kelsen, Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, in: VVDStRL 5 (1929), S. 30 (39 f., 59). 奧地利學者的見解還可參Albrecht Weber, Die Individualverfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Urteile, in: Heun/Starck (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit im Rechtsvergleich, Drittes deutsch-taiwanesisches Kolloquium vom 2-3. Oktober 2006 an der Georg-August-Universität Göttingen, 2008, S. 77 (77-91).

10 參閱Werner Heun, Normenkontrolle, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. I, 2001, S. 615 (615 ff.). 說得很斷然：「沒有規範控制，憲法法院將無法落實其維護憲法的功能」。

定¹¹。換言之，規範審查不只有法律技術上的特別難度，更因觸及抗多數決的正當性障礙，交給以一般方式選任而又在科層體制下管理，以法律忠誠執行者自許的法官去承擔，特別對深植法治國（*Rechtsstaat*）傳統的大陸法系國家而言，委實難以跨越。相對於此，憲法法院的設置，包括其選任方式注入的特別民主正當性，以及其多元背景、固定任期等，目的都在降低跨越障礙的困難。由此而觀，把裁判憲法化這樣無關抗多數決緊張關係的工作也一併丟給這個外加法院，又豈僅是殺雞用牛刀而已？除了規範審查以外，憲法機關的水平分權與中央地方的垂直分權，一方面因為不在普通法院、行政法院傳統審判權的範疇，其可訴性原不存在，另一方面這裡承擔爭議解決者要承受極大的壓力，同樣明顯超出一般法院的能力，在憲政上此一確認職權分配的權限（*Kompetenzkompetenz*）所以在幾個具有憲法法院原型的國家都選擇交給憲法法院這樣的特別司法者去集中處理，也是要彰顯慎重，並倚賴其更高的民主正當性，因此若認其為核心功能也不為過。至於二戰後肇建的德國聯邦憲法法院還把一些充滿價值色彩，某種程度把憲法自然法化的功能也交給這個法院，如解散危憲政黨、抵抗權、褫奪基本權、修憲界線等等。其他國家也有不少把總統或其他憲政上舉足輕重者的彈劾審判權，或攸關民主政治良窳的選舉事件交給憲法法院，足以反映其個別的憲政文化，在各該國確有其不可替代性，但恐怕就不具備普世或普適意義的核心功能了。

11 因此憲法法院使用合憲性法律解釋（*verfassungskonforme Gesetzesauslegung*）是為了調和憲法和法律的衝突，認定法律只在一定解釋方向時合憲，和普通法院使用同一概念時僅為單純法律解釋的方法，根本無關憲法和法律間的衝突，可參 *Karl Larenz/Claus-Wilhelm Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 3. Aufl., 1995, S. 159-163；新一代的法學方法論教科書，如 *Thomas M. J. Möllers, Juristische Methodenlehre*, 2017, S. 251-254，已就一般法官的合憲解釋方法另用「憲法取向法律解釋」（*verfassungsorientierte Gesetzesauslegung*），以示二者間的本質差異，也可回應憲政司法和憲法司法的各異其趣。

通過前面的分析就不難理解，為什麼到目前為止，還沒有看到那個國家——不論是否建立此制——把一般法院裁判的憲法審查看成憲法法院的核心功能。道理其實很容易明瞭，裁判是否符合憲法精神，純屬法律適用的問題，其效力及於一身，完全不到憲政的層次，也不會有影響社會秩序穩定的顧慮，和憲法機關之間的重大政治衝突更是完全無關，說這樣一個和法律適用沒有本質不同的憲法適用問題非憲法法院不可，實在找不到任何理論基礎。此所以在創設此制的德國，一開始也相當猶豫，後來決定導入時僅能在聯邦憲法法院法的位階加以規定，幾年後才修憲補進去¹²，從來沒有人認為這是憲法法院權限中不可或缺的一環。即使從憲法核心功能降低到立法政策的選擇，以各國憲法法院蓬勃發展到今天的實務，仍未顯示裁判憲法審查被普遍採行，少數持續採行者所反映的毋寧是個別國家的特別歷史情境，因此不論從制度譜系或各國實踐看來，所謂權限核心說也斷然無法成立。

表2 各國憲法法院的主要職能

國家 制度*	德	法	義	奧	西	葡	比	波	匈	捷	俄	土	希	南非	韓	印尼	臺
規範 審查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
分權 爭議	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
彈劾 審判	✓		✓	✓					✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
防衛 民主	✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

12 比如當時著名學者Richard Thoma就極力反對憲法把訴願制度納入聯邦憲法法院的審判權，可參所撰法律鑑定書：*Richard Thoma, Rechtsgutachten betreffend die Stellung des Bundesverfassungsgerichts*, JöR 6 (1957), S. 161 (184 f.).

選舉 爭議	v	v		v		v							v			v	
裁判 審查	v				v					v				v			

資料來源：作者編製，因篇幅所限，國家的選擇限於較有代表性者。

* 六個制度都經過類型化，比如規範審查在各國的程序十分多樣，從本文表一即可見其梗概，其他亦同。其中防衛性民主用的是德國憲法上的概念 *wehrhafte oder streitbare Demokratie*，包括政黨解散、抵抗權、基本權褫奪、修憲界限、憲法保護等制度。

伍、功能妥適觀點

再就審判功能而言，依專業區分的一般法院具有接近現實脈動，專業知識不斷精進，以及通過辯論程序充分掌握個案事實及爭點的諸多優勢¹³，法官不僅熟悉各該管轄領域的規範材料，經年累月接觸實務更培養出對相關社會部門種種利害糾結、人情世故一目了然的功力。到了終審法院的層次，法官對於各相關法律制度對社會的實際影響力已有更全面而深刻的洞見，從而也較能善用其制高點在某些特殊案例經由法律的續造來推動所謂微幅的社會改造。然而對於專業法院功能的付託，到了判斷法律條文合憲性時已明顯達到極限，這裡需要更宏觀、跨越而且整合不同領域的去作憲法上的價值判斷，剛好不是專業分工法官的強項，法官間的分工越細，越難期待他們基於儘可能廣泛的知識和多元的世界觀去作成足以凝聚共識的憲法判斷，而這卻正是集中規範違憲審查制優於分散制之處，憲法法院的組成本來即著眼於此，讓這些特殊管道產生的法官

¹³ 參閱 *Martin Düwel, Kontrollbefugnisse des Bundesverfassungsgerichts bei Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen. Zu einem Kooperationsverhältnis von Fach- und Verfassungsgerichtsbarkeit*, 2000, S. 293 ff.

有足夠能力以憲法去控制那些直接依憲法產出的規範，憲法法院法官的選任，乃至其審查程序，可說無不是為了回應和承擔這樣的功能而設。

換言之，同樣是憲法的適用，用在個案或者抽象規範上，功能最適的安排就不會相同。憲法法院法官的出身雖然總還是某個領域的專家，但整體而言不需要整個法院都專精於特定法律領域，因此若說到針對具體個案要在「合法性」和「合憲性」之間發現微妙的罅隙，而能精準的把憲法的規範內涵投射進去，主要還得依賴那些對相關生活領域的律動十分熟悉的人，憲法法官未必會比專業法官高明，憲法法院通常也欠缺足夠調查認定此類事實的制度工具，同樣遜色的是只有在專業法院才能累積的嫺熟處理專業法規的經驗，涉及諸如民事或刑事實體法與訴訟法、執行法之間許多錯綜複雜的配套關係，不論是這些法律在法教義學上的體系關聯或實際操作面的許多細微關鍵，往往都只有每天處理此類案件的專業法院才能全盤掌握，偶一為之的憲法法院則難免「掛萬漏一」¹⁴。故整體而言可以這樣說，憲法法院和各專業法院在違憲審查上妥適的功能區分應該在於：讓憲法法院審查抽象的規範，藉此不斷深入挖掘憲法的規範內涵，形成能凝聚社會共識的一些原則，而讓各專業法院根據這些憲法原則去審查個別的決定。特別設置憲法法院原本就是為了讓它處理對整個法律秩序有重大意義的憲法問題，如果把個別決定的救濟也全加在它的身上，當然會是難以承受之重。

不過功能最適觀點的討論若只到這裡，應該還沒有挖到真正的痛處，對憲法法院做過深入研究的人都知道，這根本只是問題的開始。作為一個「外加」的法院，憲法法院如何在功能上和既存的各

¹⁴ 即使在各法域教義學都相當成熟的德國也是如此，有關德國憲法法院審查裁判的程序或實體法律見解是否合憲，不夠周延乃至根本外誤的指摘，相當常見，較早的整理可參比如Christian Starck, Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichte, JZ 1996, S. 1033 (1038 ff.).

審判權體系在功能上做最好的分工，只要想到普通法院在做法律的憲法化時不可能不解釋憲法，而憲法法院在審查法律的合憲性時，也不可能不解釋法律，二者如何共存共榮，各展所長而創造最大的綜效，而非一國兩制，各執己見以致人民無所適從，甚至勢如水火、相互傾軋，在制度選擇上就會是很重要的指標。如果走到這步田地，像德國的憲法法院那樣，有機會對終審法院裁判再做一次憲法審查，就不會一無是處，增加這一層級的審查，至少可使憲法法院有機會全盤掌控憲法的發展。換言之，往好的方面看，當個別公權力行為的憲法控制完全交給專業法院時，固然河水不犯井水，可使專業法院在個案中尋求法律的適當續造，因為憲法活水的泊泊挹注而打開更寬廣的空間，憲法的內涵也可避免每次都在抽象層次作成決定，而流於僵化，且專業法院建立於豐富案例上的憲法適用，與憲法法院綜觀全局尋求社會共識的憲法適用，不啻在分工的基礎上持續進行對話而可互補。然而同樣可能存在的隱憂是，這種分工會不會導致憲法某種程度被割裂的危險，只專注於抽象規範的憲法法院發展出來的宏觀思考模式，和專業法院盯牢個案的微觀思考模式，會不會有意無意的漸行漸遠。儘管憲法法院的解釋有普遍的拘束力，專業的終審法院同樣受其拘束而不能牴觸，理論上前者應該可以主導憲法的解釋，但因為兩者間未必扣得很緊，專業法院要另闢蹊徑走自己的路，不一定找不到空間，因此即使不是各自為政，仍然可能逐漸在某些地方產生微妙的光譜上的不一致。這可能正是德國的裁判憲法訴願制度面對越來越激烈的廢止呼聲，迄今仍然屹立不搖的一個原因。但另一方面，也正因憲法法院可以排闥直入的審查終審法院的最終決定，不論最後在認定違憲時是不是僅只發回終審法院而不直接改判，也不論審查的範圍嚴格限縮於憲法的觀點，以避免所謂超級上訴審（Superrevision）的印象，但終審法院四個字已經名不符實，如果加上憲法法院審理時難免的逾越分寸，憲法法院與終審法院的戰爭就很難避免。南非的憲法法院從1993年成立到2013年修憲，就是這樣變遷（奪權？）過程的現身說法，原

來只是與最高法院平行的憲法法院，後來因為實務上實在沒辦法講清楚裁判違憲和違法的區別，乾脆修憲把憲法法院的職權改為所有法律事件的終審法院。其他借鑑德國憲法法院模式的國家如捷克，以及從其傳統amparo制度發展出來類似裁判憲法審查的西班牙，則無一不是衝突不斷，讓許多後發者望而卻步。足見在最高法院的確定終局裁判之後，要再讓另一法院就同一訴訟標的重做一次判斷，是無論如何都無法妥善設計的難局。西班牙的憲法法院即曾在一個有關名譽權保護的民事案件中，認定法院判定的賠償金太低而自為提高賠償金的判決，引起法院對其不尊重民事專業極大的反彈，但同案如果憲法法院只能撤銷發回，而最高法院又確認縱加入了憲法法院有關人格權的見解，結果並不影響原判的損賠金額，難道憲法法院不會認為最高法院未尊重其憲法判斷而發飆嗎？這還只是從憲法和法律觀點在解釋方法上可以分得開的情形所生的爭議，實際上什麼是憲法觀點，什麼是法律觀點，德國憲法法院嘗試的各種區辨憲法和法律觀點的所謂「公式」(Formel)，如赫克公式(Hecksche Formel)、舒曼公式(Schumannsche Formel)、模非斯多公式(Mephisto-Formel)，乃至史塔克公式(Starcksche Formel)¹⁵等，依其學者的整理，也從來沒有很高的可操作性，其結果就是方法上的混亂加上審級功能的扭曲。

同樣的，基於推定立法者合憲而作的合憲法律解釋(verfassungskonforme Gesetzesauslegung)，因為是以介入法律解釋為其方法，何嘗不會強烈觸及司法內部分權的敏感神經，使得設置憲法法院的國家在這裡也要尋找恰如其分的分權方式。未設憲法法院，而使各級法院的法官都可以隨案把法律合憲疑義當成先決問題

15 依Christian Starck教授的主張，基於憲法的框架性格(Rahmencharakter)，應該重新思考兩者間的功能區分，憲法法院的違憲審查應該只限於以下範圍：事實調查是否恣意，法律適用的見解是否可以一般化為規範，而有抵觸基本權保障之虞，以及法官所做的法律續造是否已經逾越界線，Weber把這也歸類於一種公式，參閱Starck(Fn. 14), S. 1039; Weber(Fn. 9), S. 84.

去作決定的美國，正因為只是就個案爭議順道處理法律違憲問題，先天上更傾向於只作「因以此種方式適用該法律條文才達到違憲」(unconstitutional as applied)的決定，這時他們完全不需考慮和其他法院體系的分工問題，只有在法院分流的國家，當憲法法院做成這樣強制刑法、行政法如何解釋的中間決定時，對於普通法院、行政法院當然會造成衝擊，這時怎樣通過逐案的互動摸索出不同的決定態樣，需要機關間展現特別高的視野和氣度，當然也和憲法法院、傳統法院各自在社會上享有的權威地位有多大差距，脫不了關係。風暴能不能止於茶壺內，每個國家的情況不太一樣。以終審法院佔有更多天時、地利的韓國為例，大法院不僅是各法律領域爭訟、非訟事件的終審法院，而且掌理全國司法行政，集司法權於一身，一如日本的最高裁判所，而且在終於下定決心另組憲法法院時，其組成方式仍然參考的是義大利的憲法法院，也就是把九個法官職位分成三種來源，三分之一由總統提名，三分之一由國會提名，三分之一由大法院提名。大法院的院長甚至刻意保留最優秀法官給自己的大法院，以壓低憲法法院的聲望。在勢不如人之下，憲法裁判所只好把僅有的權限都用到極致，卻也使得兩大法院之間幾度劍拔弩張，憲法裁判所用合憲解釋方法做成的「變形決定」，就成了重要的導火線，兩機關在最初十年間的鬥爭，堪稱高潮迭起，目不暇給¹⁶。由上可知，即使從功能最適觀點來看，把個案決定的憲法審查功能配置於普通法院，而使憲法法院專注於規範審查等真正的憲政問題，也是較佳的制度選擇，但如何使普通法院的釋憲和憲法法院的釋法能通過憲法法院和終審法院有效的互動來克服一國兩制的危機，仍須做進一步的檢視。

16 可參蘇永欽，夏蟲語冰錄（九十三）：活法作為違憲審查的標的，法令月刊，66卷10期，頁117-127（2015年）。

陸、和諧互動觀點

我們若深入思考這個潛伏於「抽象個案」分權下的一國兩制危機，就會發現義大利、法國、匈牙利等未採裁判憲法審查的國家，通過審查活法（*diritto vivente*, *living law*, *lebendes Recht*, *droit vivant*）的方法基本上已可克服，而臺灣則在先後受理對判例（司法院釋字第153號、第154號解釋）、決議（司法院釋字第374號、第420號解釋）、案例（司法院釋字第395號、第446號解釋）的審查後，也大體解決了這個問題。以下先簡介前者。

義大利憲法法院導入活法審查的主要考量，倒還不在於抑制普通法院憲法見解的脫序，而在藉以釐清最終釋憲權和最終釋法權的楚河漢界，特別是為了避免因為憲法法院行使釋憲權時因不必要的「合憲法律解釋」而被認為實質侵入了普通法院釋法權的領域，幾乎所有設置憲法法院的國家都很難避免此類爭議。義大利在二戰後建立的憲法法院和歷史悠久的最高法院、最高行政法院，卻能在旗鼓相當的態勢下，猶如文火慢熬，逐筆畫出了像Uffizi美術館的無數佳作一樣精緻的互動規則。和許多憲法法院相同的是，其違憲審查的主軸也在於人民通過法官向憲法法院聲請判決法律（含法規命令、緊急命令）違憲的程序，但憲法法院很早就建立了活法的原則，為劃清釋憲和釋法的楚河漢界奠定了穩妥的基礎¹⁷。對於法官提出來的法律違憲的聲請，義大利的憲法法院可為單純有理由成立的判決（*sentenze di accoglimento*）或無理由駁回的判決（*sentenze di rigetto*），前者有使法律失效的普遍拘束力（*erga omnes*），後者則只拘束聲請法院（*inter partes*）。但憲法法院在認定法律是否違憲前

¹⁷ 以下引介主要參考Jörg Luther, *Die italienische Verfassungsgerichtsbarkeit: Geschichte, Prozessrecht, Rechtsprechung*, 1990; Tania Groppi, *The Italian Constitutional Court: Towards a "Multilevel System" of Constitutional Review?*, 3(2) J. COMP. L. 100, 100-17 (2008).

勢必要先對法律做成解釋，而面對原因案件呈現的特定生活事實，法律解釋不再是法條（*disposizioni*）的抽象釋義，而會形成義大利法學向來用以和法條區隔的具體法規範（*norme*）——其內容可能結合了數個法條，也可能是一個法條裡演繹出的數個規範之，總之其涉及的法規範事實一定「多於」法條而為具體化法條的規範： $D = T(a, b, c) \rightarrow R$ $N = T(a, b, c, d, e) \rightarrow R$ ，此一標的上的精緻區隔和轉換，為合憲性解釋提供了方法論的基礎，再結合法原則，有心緩和兩種法院間和司法立法兩權間緊張關係的憲法法院，便有足夠論證工具而可進退裕如了。碰到法院提出的法律違憲主張，其法律解釋如不符合終審法院早已定於一的見解（活法），或者在無法認定已形成活法的情形，違反憲法法院依穩妥解釋方法認定的法律意旨，通常它會作成無關憲法的糾正判決（*sentenze correttive*）。但若法院的法律解釋沒有明顯的瑕疵，則會作成縮小打擊面的解釋性判決（*sentenze interpretative*），此時因為是以憲法引導法律解釋，和終審法院釋法權的衝突即難避免，憲法法院便會善用活法原則，把二者的衝突降到最低。1956年憲法法院首度參考了德國憲法法院在1953年創設的合憲法律解釋，作成解釋性的駁回判決（*sentenza interpretativa di rigetto*），其主文形式為：「系爭法條如循此方向解釋則與憲法尚無不合」，對於此一突破，除了對聲請法院當然有拘束力外，是否也拘束其他法院，憲法法院有意的保持低調，在同年另一件判決中就提到「系爭法條仍存在其他解釋可能性，故本院不排除未來就同一法條重新審查其合憲性」。但到了1960年代隨著這類解釋性判決的增加，眼見一般法院都想當然的認定一律不生普遍效力，憲法法院即開始以活法為理由加重其違憲控制，簡言之，對於法院所提法律違憲主張，如憲法法院確認該法規範已屬穩定的活法，而系爭法條又還不到全部違憲的程度，這時憲法法院就會選擇作解釋性的成立判決（*sentenze interpretative di accoglimento*），其主文形式為：系爭法條「就此部分」（*nella parte in cui*）或「在此範圍內」（*in quanto*）已達違憲，只有這種限定違

憲的判決才有普遍的效力（限定合憲的判決則只拘束聲請法院）。憲法法院通常不會立即走到這一步，而要等到法院實務顯示其守憲的態度十分泄沓時，才會作這樣比較強硬的決定。因此相對於有些國家雖有限定合憲、限定違憲的選項，卻始終未能建立清晰的標準，義大利憲法法院在處理以個案為基礎的法律違憲審查時，通過活法判準的運用，早已發展出可預見性甚高的操作方法：1、如果聲請法院對法律的解釋與活法不符，原則上只要以糾正判決駁回即可。2、如果就該爭議還沒有形成一致的活法，則可作成解釋性駁回判決，指示聲請法院朝合憲的方向解釋法律。3、如果聲請法院對法律的解釋符合活法，而與憲法已難相容，則在系爭法條還有合憲可能時，即作成解釋性成立判決，實質上等於認定系爭法條部分違憲，惟和真正部分違憲判決不同的是，此處有調整義務的不是立法者，而是司法者。

活法理論最大的優點，就在其對各終審法院最終釋法權的尊重，嚴守釋憲釋法各自的界線，通過相互尊重，反而更能讓憲法的規範力有效的穿透法院實務。所謂的活法，概念上源自有法社會學宗師美譽的奧地利學者Eugen Ehrlich，義大利憲法法院曾在一件判決中這樣描述活法：「本院為法律的違憲審查時，除了必須解釋作為審查基礎的憲法外，還要解釋作為審查標的的法律，此時不能不審酌法院實務對該法條一貫的解釋，因為該法條在法律生活中的價值是以此方式才產生的。故真正的法規範不是形式上被抽象編寫出來的文字，而是通過法官為了使該法條獲得實踐，日復一日操作的具體內容。」活法原則上以法院的實踐為認定對象，特別是幾個終審法院，而且要經歷一定的時間。僅僅行政部門經久長行的實踐，則不能認作活法，但近年已漸放寬，對於行政部門的法條解釋（通過各種函釋、規則），「若其影響層面達到相當程度而已可認定為一新法制」時，也可算是一種活法。義大利這種把實際上由法官具體化的法規範而非抽象法條納入審查的作法，漸漸為歐洲許多同樣以

抽象法律為違憲審查標的的國家所仿效，1993年匈牙利的憲法法院就在其院長和義大利憲法法院院長交流之後的兩週，現買現賣的把活法原則寫進他們的判決。2008年才修憲導入對法律作嗣後違憲審查制度的法國，其憲法委員會也很快的就在2010年10月6日的一個決定中確立對活法審查的原則，認為「法律穩定且恆常的解釋（une interprétation jurisprudentielle constante）已經和法律密不可分，故可作為違憲審查的客體。」只有對於開放憲法法院審查終審法院裁判的國家而言，任何具體個案的法律適用都可由憲法法院再作一次違憲審查（不問是否達到活法的程度），終審法院的釋法權實質上已經任人宰割，再把活法視同法律納入審查，自然完全多餘。這個讓憲法法院直接把手伸進所有確定裁判的制度，固然同樣可以確保憲法全面且一致的實施，但如同開放所有案件進入延長賽，已無確定可言，且憲法法院既因消耗大量資源於小案而影響其整體憲政功能的伸張，終審法院也為其釋法權威的受到重創、專業的不受尊重而深感不平，即使在裁判憲法訴願原創國的德國，釋憲和釋法的分權都已顯得捉襟見肘乃至怨聲四起¹⁸，少數的繼受國，如南非、捷克，則幾已難以為繼¹⁹。正因為憲法法院和最高法院的分際已無法維繫，南非已經在2012年正式修憲把憲法法院變成唯一的最高法院，乾脆放棄了原來另設憲法法院的理念！相形之下，活法原則的操作，才可為憲法法院和傳統法院的共存共榮，找到有如達文西構圖的黃金比例。

18 德國學者也有疾聲呼籲憲法法院和專業法院建立合作關係者，方向仍不外乎限制憲法法院審查裁判的範圍，可參Gerhard Robbers, Für ein neues Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und fachgerichtsbarkeit - Möglichkeit und Inhalt von „Formeln“ zur Bestimmung von verfassungsgerichtlicher Kompetenzweite, in: Bogs (Hrsg.), Urteilsverfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht: Ein Grundrechts-Colloquium, 1999, S. 57 (63-67).

19 捷克情形可參Düwel (Fn. 13), S. 293.

從這個角度看地球另外一頭的臺灣，當大法官把各終審法院的判例和決議納入審查後，憲法法院也以類似審查活法的方法和各終審法院建立了友善的制度互動，既沒有直接介入個案審判權，因為判例和決議就是制度化的活法，在釋憲權和釋法權的互動上，相互都得到了最大的尊重。換言之，當大法官對專業法院的決定去作憲法控制時，如果都聚焦於通案的活法，而不是個案決定的見解或做成決定的程序，不僅最能發揮功能，同時也留給終審法院足夠空間和權威，去就個案相關法律與憲法規範在個案中的交互影響去作最終的評價與決定，這也最符合一般法官的專長。從某種角度我們似乎可以說，義大利的活法和臺灣的判例決議，都為憲法法院和終審法院找到了一條黃金中線，即使這種制度化的活法已將完成階段性功能而走入歷史²⁰，未來將以大法庭制度取代總會決議，並由審判

20 臺灣大法官以解釋走出來的新權力領域，當然不是毫無爭議。終審法院的總會決議因為沒有法律依據，不是得到公認的法源，法院在裁判中也很少援用。即使有法律依據並正式公布的判例，也沒有絕對的拘束力而只能算是一種「軟法」，法官雖常援用，但並沒有援用的義務。大法官先後把這兩種抽象規範納入違憲審查的結果，先是引起法院的不滿，等到反對聲浪漸熄，專業法院的裁判又逐漸形成儘量不引用判例的習慣，有時寧可逐字抄錄判例要旨，卻不公開引用判例文號，大法官對付此種匍匐前進的策略，就是對是否援用判例改採實質判斷，不論終審法院的裁判有沒有引用判例文號，也不論其使用文字是否與判例要旨完全相同，只要認定裁判事實上採用了判例的內涵作為主要理由，後來甚至擴張為只要裁判結果在論理上可以和某個判例連結，大法官就可能把該判例納入審查。發展到極致時，大法官竟在該終局確定裁判既未引用判例，甚至也很難說有實際依其法理操作的情形下，仍然武斷的認定數個判例具有裁判關聯性而納入審查，當大法官在程序上有意受理而受到最高法院強烈反彈時，曾直接去函最高法院詢問承審法官在審理本案時是否確有援用判例的意思，得到的答案雖是明確的否認，大法官仍然決定受理對該數判例的審查，最後並作成兩件判例違憲（司法院釋字第582號解釋），像這樣猶如貓捉老鼠的遊戲實已到了荒腔走板的程度。司法巨塔之間的關係會如此扭曲，部分的原因還是在於判例與決議仍停留在行政而非真正審判造法的落伍作法，顯然這一條黃金中線也還有很大的改進空間。近年司法院已推動以大法庭替代總會決議的政策，同時正式終止判例的製作，未來在去行政化後還可以借鑑義大利的活法方法，建立大法官和終審法院法官揖讓而升的平台。有關兩岸司法行政造法可參見蘇永欽，司法造法幾樣情——從兩大法系的法官造法看兩岸的司法行政造法，中德私法研究，17期，頁3-47（2018年）。

實務形成的長期一貫見解共同構成活法，大法官的規範審查自然也可以延伸過去，其操作方式應可借鑑義大利、法國的經驗，比如大法庭建制後，其統一歧見的判決，應該也是一種制度性的活法，只是大法官可納入審查的，不會是大法庭的判決本身，因為此一判決創設了統一歧見的法規範，邏輯上不可能是自己所「適用」的法規範，大法官可以審查的應該是後來被援用或實質援用於其他案件的大法庭判決，而且審查的不是該判決，是判決內含的普遍性法規範（活法）。除了這些制度化的活法外，不論法官或人民於案件繫屬中聲請判決「應適用」的法律違憲，或人民就確定終局裁判「所適用」的法令違憲，大法官都還可以依聲請或依職權調查認定有無客觀存在、法院普遍長期採用的法條解釋，而以其為活法進行違憲審查。果然認定違反憲法意旨時，應先判斷法律有無其他解釋的可能，若已無可能，即應直接認定相關法令違憲，若仍有可能，則可以做成法條合憲，僅該部分法規範（活法）違憲的判決。比起過去含混不清的以實質援用強把法院無意援用的法條或判例、函釋納入解釋，要好得多。以過去的實務來看，用這樣的方法來處理兩岸重婚案件的司法院釋字第242號解釋，和共同被告詰問證人權的司法院釋字第582號解釋，就可能更合理而順暢。但在認定這類未制度化的活法時，當然要特別謹慎，尤其針對確定終局裁判被指摘所適用的法令牴觸憲法的情形，除從裁判的理由論述可以認定，該裁判實際適用者確實為各級法院長期反覆解釋相關法條（單數或複數）而形成的穩定法規範，才能就該法規範進行審查，而非直接審查該裁判就法律適用表示的見解，並於確認違反憲法意旨後即作成法條合憲但其法律解釋違憲的解釋，等於是「假法律審查之名行裁判審查之實」，裁判憲法訴願制度所有的問題也都會跟著進來。至於具體認定活法存在需要做到什麼程度，比如由聲請人舉證終審法院各庭均無相異見解，或可由大法官函請終審法院表示意見，這樣的程序問題都還有待各界共同思考。

相對於此，以裁判憲法訴願打亂了功能最適分配及各審判權間和諧互動的德國，已很難跳脫歷史形成的制度枷鎖，即使按 Starck 教授所提的方向限縮，恐怕也只能把損害降到最低而已。

柒、機關產能觀點

再從機關產能的觀點來看，憲法法院的人力有限，又必須反映多元背景，本來就不適合處理大量案件，像專業分流法院的合議庭那樣。現在要不分審判權的把各種案件的確定裁判都開放進來，由其多做一次憲法的審查，僅從數量來看就知道不容易做到。以大法官目前每年新收案件5、600件來推估，如果暴增到5、6000件，也不會太意外。當然這裡既非人民訴訟救濟的核心保障範圍，在合理條件下賦予大法官某種選案權應該沒有問題，但如果要避免過度排擠屬於大法官核心職能部分——規範審查、機關權限爭議、中央地方分權爭議，乃至政黨解散、總統副總統的彈劾案件——，其受理比率勢必壓到非常低，則且不說程序的處理仍要耗費龐大資源，以何種組織與程序選案，如何求其標準的一致，避免設置大量助理而淪為「助理審判」的詬病，會不會憑空製造更多司法信任的問題，從德國憲法法院不斷調整其法院組織與程序，乃至修法調整選案標準，即知其艱難。為消化大量案件，德國自始即設置了比絕大多數憲法法院規模要大的16位法官，還得勉強分成兩個法庭（Senat）——寧可忍受有時難免意見分歧的後果，後來為了快速處理接近萬件的裁判憲法訴願，把駁回訴願的繁瑣工作另交三人小組（Ausschuß）處理，再過幾年又得修法設置法庭下的小法庭（Kammer），並不斷擴張其職能，這個非核心職能對於其核心職能造成的排擠有多嚴重，憲法法院雖不會明言，但數字會說話——兩個庭加起來的效率還不如其他國家一個庭，德國唯一寫了一本憲法訴願專書的重要作者Rüdiger Zuck就直言，讓憲法法院審查個案裁

判根本是本末倒置²¹。

工作量的問題還不只於此。在人民聲請的規範審查現制下，考慮到法秩序安定的重要，我國和多數國家一樣參考奧地利的作法，僅使違憲法令向後失效，只有聲請人為表彰其對憲法的貢獻可以就原因案件得到再審或非常上訴的機會，對於其他有相同情形，但沒有聲請解釋的人民，其案件就不得聲請再審，以同一理由聲請大法官解釋同一法令，大法官可以一事不再理駁回。就此不問審查的標的為法律、命令，或制度化的活法——判例、決議，都無不同，未來改革判例、決議制度，即使借鑑義、法等國，把所謂長期一貫見解的活法納入，也只是把審查對象從法條延伸到具體規範，其效果不變，即除聲請人得到特別救濟外，有類似情形者若要提出仍會受到一事不再理的限制。但如果碰到裁判憲法審查，對於相同情形受到不利判決的人民，以同一理由聲請大法官審查，因為不在前案既判力所及，大法官不能再以一事不再理而駁回聲請，這時就得一一比對是否相同案件，而以小法庭的簡易程序快速處理，案件量會有多大，更難評估，是否「相同案件」而可援先例做成決定，方法上又有不小的問題——一定程度上可能得引進英美法的先例拘束操作原則。德國的實務顯示，僅僅就比對「是否類似」問題，就可能造成極大的負擔，大法官投入於小庭的時間早就不比大庭少，就工作的質量而言實質上已經是小法官，而且果若類似案件都能得到救濟，「向後失效」的原則在這裡已經顛覆，也會造成體制上的矛盾。相對於此，以活法的審查替代單純個案裁判審查的國家，一方面改善了抽象審查法條的問題，另一方面還可避免重複審查個案的雷區，既維持了司法內部分權的和諧，也保留了足夠資源去處理真正的憲政難題。

21 參閱Rüdiger Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 2. Aufl., 1988, S. 96 f.

捌、民主轉型觀點

還有一個可能支持憲法法院對裁判進行憲法審查的理由，就是民主轉型的特殊需要。政治學上的新制度主義一直把90年代大片社會主義國家的轉型，當成最好的理論實驗室，果然我們也在那裡看到一些西歐民主國家較為罕見的憲法訴願制度，如阿爾巴尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞等。需要嚴肅追問的當然還是：真的有助於民主轉型嗎？在何種條件下？

幾十個社會主義國家的走向民主體制，確實是人類歷史的重大轉折（福山的歷史終點論），其主要推動或支持力量幾乎都是「我們人民」（We the people）。因此轉型期間的制度選擇多有鞏固民主的內涵，此所以人民也常被賦予特別的角色，為成熟國家所無，如直選總統，公民投票等，違憲審查制度如何善用人民也是重要關鍵。對轉型國家而言，國會和法院同樣背負舊體制的若干包袱，但以鞏固民主的需要而言，對國會進行司法控制可能更為迫切。匈牙利等國甚至以民眾訴訟的高度客觀化方式來重建法制，藉此避免後共時期的多數決部門因新興政黨的脆弱而予共產黨復辟之機。相對於此，已經成熟的民主國家有較為穩健的多數決部門，反而會選擇給予國會較大的試誤空間，此時轉向中間型的、兼顧規範控制與基本權救濟類型，反而是更好的功能分配。這樣的比較當然無意否定憲法訴願的特殊民主鞏固功能，事實上當憲法的規範性長期受到壓抑而未能被正確認知時，由憲法法院帶頭護憲可有火車頭的作用，如果法院長期都過於重視法律而忽視人權，此一火車頭作用更為明顯，德國、西班牙和南非制度的歷史背景即可合理化此一功能性低的制度，但這前提是火車的身體儘可老舊，火車頭必須全新打造，才能擺脫歷史的包袱。德國在制訂基本法的時候，即已意識到劫後餘生的司法體系，背負了太多惡法亦法，乃至善法也被惡用（如創設所謂猶太人「市民死亡」的概念）的紀錄，被貶抑為「棕色司

法」，其法律專業的能力並不足疑，但納粹政權的洗腦已經抽掉了實定法大部分的道德內涵，因此亟需建構一個全新的法院，像迷霧中的燈塔一樣帶領所有法院前進——這正是德國前憲法法院法官Hoffmann-Riem教授的比喻，也讓戰後的人民可以回復對司法的信任。所以制憲先賢不是不知道憲法訴願必須付出的代價，但如果這是最能短期見效的抗生素乃至類固醇，他們也寧可如此。90年代的社會主義國家轉型，很多可能也是建立在這樣的思考上。

兩相比較，臺灣的轉型可說有本質上的不同。Samuel Huntington的第三波民主理論，把臺灣歸類為一次到位類型，從硬性威權到軟性威權，再成功轉型到民主體制，釋憲的大法官和釋法的各終審法院都是在民主化的過程中一起成長，坦白說當普通法院的憲法意識還明顯低落時，當時的大法官也並不高明多少。1980年代法學院的學生已經能學習到相當豐富的憲法知識，等他們成為法官時，腦中的人權意識比起當時大法官在同樣年齡時期應該深刻得多，由下而上的審判獨立改革實際上就是由年輕法官點燃。因此借大法官的法相金身宏大憲法意識的策略，先天即有困難，到了民主化快三十年的今天，才想起複製1949年德國的司法新制，更給人時空錯亂的感覺。這麼說完全無意抹殺大法官解釋對於民主化的和平實現，以及嗣後的鞏固所做的巨大貢獻，對於普通法院憲法意識的強化當然也起了相當作用。只是到了現在還泛言藉導入憲法訴願來教育一般法官，真的有點不倫不類，如何讓司法體系內同樣臻於成熟的這兩種司法權找到最適分工、揖讓而升之道，恐怕才是後轉型時期需要司法當局全力投入的使命。

玖、路徑依賴觀點

儘管德國採行的裁判憲法訴願制度有諸多問題，支持廢除憲法

訴願或「至少」廢除裁判憲法訴願的德國學者確實不多，但認為這個制度問題重重的人，從來沒少過。而且每隔幾年憲法學界就會掀起一陣檢討的熱潮，因此制度也才會經歷了多次的調整。也許我們應該先從憲法的底線來問，是不是有什麼憲法的理由，非要建制憲法訴願不可，才使得堅決主張廢除者，儘管都是對這個制度研究最深者，包括前面提到的Zuck，和後來當上憲法法院院長的Andreas Voßkuhle，就算加上對其實務提出頗多質疑的憲法訴訟法重要教科書作者如Christian Pestalozza和Stefan Koriöth，整體來看仍然顯得勢單力薄。比如說，沒有憲法訴願，會不會形成人民基本權保護的漏洞，所以再怎麼不好，基於保障基本權的考量，多數人還是不輕言廢除？但這一點恰恰又是Voßkuhle院長講得最清楚的地方：憲法的要求必須在所有司法程序中被仔細檢視，不能因為另有憲法法院而被忽略，因此裁判的合憲性，包括基本權是否受到保護，在一般法院的審級救濟中已經都被審查過，憲法法院有時還會以起訴者在一般法院救濟過程中從未提出憲法主張為不受理的理由。至於一般法院能不能善盡審查的義務，也許在上世紀五〇年代的後納粹時期大家還會有一些懷疑，半個多世紀過去，現在無論如何已經沒有這個問題，所以他才會在出任憲法法院法官前即罕見明確的力主「至少要廢除裁判憲法訴願」，所持理由除了實際上只有3%的案件會被法院受理，不僅造成司法資源極大的浪費，也使民眾倍感失望的實效分析外，更強調：「在憲法法院已經出版上百卷涵蓋極廣的案例集以後，還需要擔心一般法官不知道如何在承審案件中恰如其分的納入憲法觀點嗎？」²²

那麼為什麼這個CP值極低、影響憲法法院資源分配極嚴重的制度，到現在還沒有廢止？仔細閱讀相關檢討，憲法法院因它而散發的歷史光芒幾乎已經是唯一的理由。Joachim Wieland的一個總結

22 參閱 Andreas Voßkuhle, in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz Kommentar, 4. Aufl., Bd. 3, 2001, Art. 93 Anm. 166.

應該就是最好的回答：「聯邦憲法法院能在德國法律秩序中建立如此崇高的地位，與它承受如此龐大的案件壓力，都是拜憲法訴願之賜」²³。Rainer Wahl教授詳細整理了正反意見，他的結論也是一樣：「德國模式的司法違憲審查，因憲法訴願的存在而存在，也將因憲法訴願的廢除而消失，一旦沒有憲法訴願，德國的司法違憲審查將變成另一個東西」²⁴。他的意思是，即使變成的是「更好」的東西，也寧可不要。路徑不僅會帶給人們一種安定感，這個例子說明它也可能讓用路人沈浸於過往的光榮。Wahl寫在慶賀聯邦憲法法院成立50週年文集的這篇文章就很直白的說，每個憲法體系都會形成高度的路徑依賴（Pfadabhängigkeit），「不隨便改弦易轍當然有它的道理」²⁵。用路徑依賴理論的說法，就是這個二戰後首先在德國創發的制度，它的正面的花車和網路效應也許在第一個10年就已經發揮到極致，以後其實就是不斷投入卻不見真正改善的鎖定狀態（lock-in）。

因此真正要問這個問題的，還是法制的後發國家，社會科學已經有深入研究的路徑依賴理論給我們的啟發也許正是：對尚未被鎖定的後發者而言，現在正是突破前人、超越前人的契機。後發者思維首先需要建立後發者的意識，在各自向前的時候，許多跟隨者會不自覺的變成永久的跟隨者，即使走在自己的路上，仍渾然不覺的跟隨某一前行者。開路人要有超越用路人的想像，因為我們有機會走出一條更好走的路。通過比較而瞭解某一成功典範，其路徑形成的正反向回饋和相關效應，從而掌握超越的機會，這才是開路人應

23 參閱Joachim Wieland, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, Bd. 3, 2000, Art. 93 Rn. 72.

24 參閱Rainer Wahl, Die Reformfrage, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. I, 2001, S. 461 (474 ff.); 相同論調還可參閱Eckart Klein, Die Zukunft der Verfassungsbeschwerde, in: Piazzolo (Hrsg.), Das Bundesverfassungsgericht: Ein Gericht im Schnittpunkt von Recht und Politik, 1995, S. 227 (236 ff.).

25 Wahl (Fn. 24), S. 466.

有的思維，也是人類法治能夠不斷進步的關鍵，所謂青出於藍而更勝藍，考驗的就是這個。

拾、立法技術觀點

最後，我還要從立法技術的觀點來檢討一下司法院的提案，也就是再撇開立法政策的不妥，即從立法技術的角度來看此一重大修法，也無法理解為何會犯下如此嚴重的錯誤，似乎正折射出決策者的輕忽心態，過多司改大旗下的政治表演，掩蓋了司改決策最起碼的制度理性。

既然標榜以德國的裁判憲法訴願為師，就應該知道這是德國聯邦憲法法院眾多客觀程序外刻意加入的、以保護人民主觀基本權為目的的主觀程序，只要對照德國基本法和聯邦憲法法院法的相關規定即很清楚。德國基本法第93條第1項列舉憲法法院的職權，其第4之1款對憲法訴願的規定就是：「憲法訴願，可由任何主張其基本權或本法第20條第4項、第33條、第38條、第101條、第103條、及第104條所規定之權利，遭受公權力侵害者提起。」同樣內容複製於德國聯邦憲法法院法第90條：「任何人得主張，其基本權利或在基本法第20條第4項、第33條、第38條、第101條、第103條、及第104條所規定之權利，遭受公權力侵害，而向聯邦憲法法院提起憲法訴願。」顯見此一程序的核心理念，就是人民「主觀憲法權利」（基本權清單內的基本權和其他憲法規定賦予人民的權利）的保護，在憲法法院成立備忘錄中，也就此反覆宣示。但司法院在提出此案於司改國是會議時，卻因分組中有留美的法官建議不要用易滋誤會的「訴願」概念，直接叫裁判憲法審查，大家不假思索也就採納。但訴願的概念固然不妥，德文Beschwerde真正要彰顯的是主觀權利的保護需要，而不只是如抽象或具體規範審查（Normenkontrolle）程

序彰顯的客觀憲法秩序的維護，一如德國和我國民法侵權行為的侵害權利與違反保護他人的法律是兩種不同的基本類型，至於中文怎麼表達，倒還只是如何使其概念更精準妥適的問題。換言之，憲法訴願不論哪一種——針對法律、命令或裁判，如果不以該公權力直接侵害訴願人的某個基本權，程序即不合法。發動程序的人民不是要憲法法院審查某個抽象規範或具體決定的合憲性，以排除該違憲狀態；而是要憲法法院為人民提供救濟，排除對他或她的某個基本權的侵害。因此同樣由人民發動，Georg Brunner教授把我國現制這樣以排除違憲狀態為程序標的者一律稱之為「非真正基本權訴願」，只有為特定人民主觀基本權遭受侵害提供救濟者，才是真正的基本權訴願。現在立法院通過的大審法修正案，儘管提案的司法法院一再標榜以德國的憲法訴願為師，卻可能因為國是會議通過的是「裁判憲法審查」，竟然就朝客觀程序的方向去設計，和現制有關人民聲請的程序一樣，只把審查客體從法令擴張到裁判，主觀基本權被侵害的要件反而完全不見了：「人民就其依法定程序用盡審級救濟之訴訟案件或非訟事件，對於受不利確定終局裁判所適用之法規範或該裁判，認有牴觸憲法者，得聲請為宣告違憲之判決。」（第59條第1項）從本條說明可以看出來，把現行大審法第5條第1項第2款的「於其憲法上所保障之權利，遭受不法侵害」刪除，是因為這個要件顯然不是作為聲請人向「普通法院」提起訴訟的原因，以此作為向「憲法法庭」提起訴訟的要件，本來就是當初立法時的誤解，沒有任何憲法理論可為依據。但既要改成憲法訴願，仍然必須要有某個公權力侵害了某人的某個基本權，在沒有抽象規範直接侵害起訴者基本權的情形，這裡就應該是某個具體裁判侵害了起訴者的某個基本權，否則向憲法法庭起訴的正當性在哪裡，豈不是擺明要把大法官變成對終審法院裁判合憲性再做一次審查的第四超級審？德國建構以保護主觀基本權為職志的憲法訴願，努力撇清超級審印象的努力，顯然不被認為有何必要，而且我們為什麼要修法增設審查個案裁判合憲性的規定，如果不是為了救濟主觀基本權的侵

害，難道也和現行法審查法令合憲性一樣，只是為了維護客觀憲法秩序？新法對於認定裁判違憲的效果，規定憲法法庭應直接廢棄該裁判發回管轄法院，難道也要認為只是表揚聲請人對憲政的貢獻，不是對其主觀基本權的救濟？這絕對不是程序法的吹毛求疵，而是必須在建制時釐清的嚴肅法理問題。沒有錯，在大部分裁判違憲的情況，可能都同時違反了某條基本權的規定，及侵害了起訴者的某個基本權，但理論上有可能沒有侵害任何起訴者的任何基本權，只是違反了基本權規定的客觀內涵，或某個憲法原則，在後者的情形，和Brunner描述的非真正基本權訴願有何不同？

過去一直有留德背景的學者建議引進憲法訴願制度，我很好奇，這樣一個可能又是舉世唯一、全面涵蓋抽象法規範和裁判的「非真正基本權訴願」，是不是他們想要的制度？我向來不認為解釋制度的司法化，必然要和程序的主觀化劃上等號，大法官違憲審查的標的也不一定要從規範延伸到個案，以抽象法規範的合憲性審查為大法官和普通法院審判權間的楚河漢界，才是兩者間功能最適的分工，前面已有充分論述。但如果認為由一般法官在個案裁判中通過憲法觀點的注入去正確適用法律（司法院釋字第9號解釋即已肯認），真的還有所不足，一定要另外增設大法官以個案裁判合憲性為訴訟標的的制度，則除了建立在主觀基本權的保護外，還有什麼更好的制度選擇，殊難想像。立法者或許以為，把裁判直接違憲和間接因為裁判所適用的法令違憲兩種情形一併規範，就只能跳過基本權侵害的受理要件，殊不知，德國的所謂裁判憲法訴願本來就包括這兩種類型，其中裁判適用法令違憲被稱為「間接法規範違憲」，是和直接法規範違憲去做比較，後者侵害基本權的公權力就是法令本身，不需要通過裁判，而這種所謂的間接法規範違憲，本質上還是裁判的直接侵害基本權，否則就通不過憲法訴願嚴格要求的「直接性」（Betroffenheit）檢驗，只能以程序不合法而不予受理了。

立法者這樣敲鑼打鼓的說要讓大法官直接保護人民的基本權，結果設計出來的整套程序卻完全見不到主觀基本權的影子，以如此不通的法理作為改制的基礎，不能雪中送炭也就罷了，竟還要錦上添花，怎不令人掩卷長嘆。

結 語

整體而言，大審法的修正目標，應該是建構一個足以回應現階段臺灣民主憲政需要的憲法法院，強化必須由大法官承擔而無可瓜代的核功能，並通過其引導，讓普通法院在個案的審理中，也能充分落實憲法的價值，使整個多元動態的法制穩定的統整於憲法之下。把個案救濟以追加一審的方式硬套在大法官的頭上，正如前述歐洲憲法法院大會中很多人批評的，會使花了好大力氣建構的憲法法院滅頂於無數的小案中，如法國學者Carbonnier所批評的「司法的民粹式消耗」(debilitating popularization of justice)，或義大利和德國學者說的「零碎化司法」(microconflittualità, Bagatelljustiz)，徒然排擠其可貴的資源，放著許多更重要的職能於不顧，臺灣未來已可預見的重大憲政問題，如生物醫學、人工智能、通訊傳播新科技之於社會家庭倫理、政治財經制度，充滿了潰堤式創新(disruptive innovation)，因而對人民基本權和政府分權負責體制造成的巨大衝擊，早已無法避免，大家都會渴望得知憲法的界線在哪裡？更不要說中央分權仍在若干關鍵處晦暗不明，地方自治問題隨著六都格局的發展方興未艾，如何讓大法官擴大產能以便一一即時回應，都恐力有未遑——只要想想前瞻案是用什麼理由不受理的！——，怎麼還會有餘力去重複處理本應分散由終審法院隨案從憲法高度仔細審理後終結的大量個別民刑行政案件，難道真的是無力回應艱鉅的挑戰，才一味遁入爭議個案，追求虛矯的人權美名。一定要問德國為什麼有？恐怕只有回到二戰後痛定思痛、非過正不

足以矯枉，而決心告別挑起兩次世界大戰罪愆過往的歷史情境，才能徹底理解，否則德國基本法還有抵抗權、褫奪基本權、全球政治受難者的庇護權、憲法防衛局等制度，我們是不是也都要全盤繼受？既非制度的必然，而是歷史的偶然，我們在規劃調整大法官職權時，就要更從放大集中審查模式的優點，減少其缺點的角度去做整體的思考，面對歐陸法系憲法法院最困難的結構問題，也就是如何使司法的內部分權恰如其分而可產生最大的綜效，許多設置了憲法法院的國家已經累積了可觀的寶貴經驗，又怎能視而不見？本文整理的諸多想法，過去都已經剴切表達過，但眼看司法院未做任何說明，即以極其片面單薄的理由，率性地把我國的釋憲制度，乃至整個司法分權體制帶往一個不可知的未來，習於非美即德、獨沽一味的憲法學界竟也視若無睹，處變不驚，怎能不令人憂心忡忡，因而敢借追思吳大法官文集的一角，抱著欽慕其全觀視野、實事求是之心，再次攀上巨人肩膀，拋出這個重大議題做空谷之鳴。如今法律雖已通過，但有三年時間準備施行，如果本文所整理的理論質疑和實務困難已可證明都無法合理解決，仍可循民法第166條之1條的先例，懸崖勒馬，就本章節另定施行期日，實所至盼。

參考文獻

1. 中文部分

吳秦雯（2011），事後違憲審查之潮流？——淺析法國違憲審查制度之新變革，憲政時代，36卷4期，頁375-409。

李鐸澂（2012），法國憲法委員會組織法、憲法委員會處理違憲先決問題內部規則、憲法委員會委員義務律令之中文翻譯，憲政時代，38卷1期，頁55-107。

蘇永欽（2015），夏蟲語冰錄（九十三）：活法作為違憲審查的標的，法令月刊，66卷10期，頁117-127。

——（2018），司法造法幾樣情——從兩大法系的法官造法看兩岸的司法行政造法，中德私法研究，17期，頁3-47。

2. 外文部分

Brunner, Georg (2002), Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Raum, JöR 50, S. 191-256.

Düwel, Martin (2000), Kontrollbefugnisse des Bundesverfassungsgerichts bei Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen. Zu einem Kooperationsverhältnis von Fach- und Verfassungsgerichtsbarkeit, Baden-Baden: Nomos.

Garlicki, Lech. 2007. Constitutional Courts versus Supreme Courts. *International Journal of Constitutional Law* 5:44-68.

Groppi, Tania. 2008. The Italian Constitutional Court: Towards a “Multilevel System” of Constitutional Review?. *Journal of Comparative Law* 3(2):100-117.

Heun, Werner (2001), Normenkontrolle, in: Badura/Dreier (Hrsg.),

- Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. I, Tübingen: Mohr Siebeck, S. 615-639.
- Kelsen, Hans (1929), Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, in: VVDStRL 5, Berlin: Walter de Gruyter, S. 30-88.
- Klein, Eckart (1995), Die Zukunft der Verfassungsbeschwerde, in: Piazzolo (Hrsg.), Das Bundesverfassungsgericht: Ein Gericht im Schnittpunkt von Recht und Politik, Mainz: v. Hase & Koehler, S. 227-242.
- Larenz, Karl/Canaris, Claus-Wilhelm (1995), Methodenlehre der Rechtswissenschaft (1960), 3. Aufl., Berlin/New York: Springer.
- Luther, Jörg (1990), Die italienische Verfassungsgerichtsbarkeit: Geschichte, Prozessrecht, Rechtsprechung, Baden-Baden: Nomos.
- Möllers, Thomas M. J. (2017), Juristische Methodenlehre, München: C. H. Beck.
- Robbers, Gerhard (1999), Für ein neues Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und fachgerichtsbarkeit - Möglichkeit und Inhalt von „Formeln“ zur Bestimmung von verfassungsgerichtlicher Kompetenzweite, in: Bogs (Hrsg.), Urteilsverfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht: Ein Grundrechts-Colloquium, Baden-Baden: Nomos, S. 57-70.
- Schäffer, Heinz (2001), in: Kneihls/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht, Vienna: Verlag Österreich, Art. 140.
- Starck, Christian (1996), Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichte, JZ, S. 1033-1042.
- Thoma, Richard (1957), Rechtsgutachten betreffend die Stellung des Bundesverfassungsgerichts, JöR 6, S. 161-194.
- Voßkuhle, Andreas (2001), in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz Kommentar, 4. Aufl., Bd. 3, München: Vahlen,

Art. 93.

Wahl, Rainer (2001), Die Reformfrage, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. I, Tübingen: Mohr Siebeck, S. 461-191.

Weber, Albrecht (2008), Die Individualverfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Urteile, in: Heun/Starck (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit im Rechtsvergleich, Drittes deutsch-taiwanesisches Kolloquium vom 2-3. Oktober 2006 an der Georg-August-Universität Göttingen, Baden-Baden: Nomos, S. 77-91.

Wieland, Joachimin (2000), in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, Bd. 3, Tübingen: Mohr Siebeck, Art. 93.

Zuck, Rüdiger (1988), Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 2. Aufl., München: C. H. Beck.